

《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定，经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。本案中，三被告单位及被告人苏某采用虚构转口贸易的方式，向银行提供了虚假的材料，让银行误以为是正常的贸易融资，其行为已经违反了国家规定，造成了外汇统计数据上的失真。

其次，该行为实际上已经将外汇非法转移至境外，符合逃汇罪的构成要件。在客观行为上，逃汇行为除要达到数额较大的要求外，还应该考察行为的实质违法性，即外汇收支是否具有真实性、合法性的基础。本案中，三被告单位及被告人苏某以转口贸易的形式将外汇资金电汇至境外公司，而其转口贸易所依据的单据均是虚假的，在银行将外汇资金电汇后，该外汇实际上已经转移至境外，构成逃汇罪的既遂。虽然之后汇至境外的外汇资金大部分有回流至境内，但外汇资金脱离国家监管已成事实，该行为将使得银行面临巨大的风险，甚至影响国家外汇宏观政策，不利于正常贸易的开展。

三、外汇犯罪罪数的认定

司法实践中，骗购外汇罪与逃汇罪的行为有诸多交织重叠之处。例如，本案中，三被告单位及被告人苏某虚构转口贸易业务向银行申购外汇并转移至境外公司，该行为同时触及两个罪名的构成要件，此时如何准确认定行为的性质及犯罪罪数，同样是值得研究的问题。

首先，骗购外汇罪与逃汇罪的界限问题。骗购外汇罪与逃汇罪均属于行政犯、数额犯，均以外汇为犯罪对象，侵犯的法益均是国家外汇管理制度，有必要在构成要件上对二者予以区分。在客观行为上，骗购外汇罪表现为使用虚假交易单据向金融机构骗购外汇，逃汇罪表现为擅自将外汇存放境外或将境内的外汇非法转移到境外，前者指向获取外汇的行为，强调的是采取欺骗手段骗购外汇，后者指向转移外汇的行为，强调的是外汇非法外流。

其次，骗购外汇罪与逃汇罪牵连犯的问题。在外汇犯罪中，实施骗购外汇犯罪同时又触犯其他罪名的情况经常发生，在本案中，行为人实施了三个行为：一是以欺骗手段取得银行的信用证；二是使用虚假交易单据虚构转口贸易向银行骗购外汇；三是违反规定将外汇转移至境外。此时骗取信用证、骗汇是手段

行为，逃汇是目的行为，三个行为并非相互独立，而均指向外汇这一犯罪对象和外汇管理秩序这一法益，应理解为同一行为链条上的不同环节，虽然触及骗取金融票证罪、骗购外汇罪和逃汇罪三个罪名，但成立牵连犯，应按“从一重罪处断”的原则适用法定刑较重的骗购外汇罪。

本案中，三被告单位及被告人苏某既有将自有外汇非法转移至境外，又有以虚假交易单证骗取银行的外汇后，非法转移至境外的行为。笔者认为，只有目的行为能够涵盖手段行为时才能适用牵连犯的原则，反之则不能适用。本案中逃汇的外汇两部分来源并不完全重合，以逃汇为目的骗购外汇的部分可以适用牵连犯择一重罪，而自有外汇逃汇的部分，因该部分不存在骗购外汇这一环节，因此无法适用牵连犯。故，本案中，应当区分两部分逃汇外汇的来源，并实行数罪并罚。

编写人：福建省石狮市人民法院 陈莉莉 曾佳乐

虚假转口贸易中“内保外贷”套利型逃汇行为的认定

—— 艾某某等逃汇案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市天河区人民法院(2022)粤0106刑初632号刑事判决书

2. 案由：逃汇罪

【基本案情】

2015年始，艾某某与同案人夏某某(另案处理)在经营被告单位某公司期间，为牟取人民币理财利息与外汇贷款资金成本之间的利差等利益，利用其控

制的某1公司等多家境内外公司，以虚假销售合同、海运提单等材料，虚构转口贸易背景，多次向金融机构购买理财产品并抵押申请远期信用证，办理购付汇业务，将493897788.35美元非法转移至境外，后再以转口收汇等形式收回资金。其中，姜某某、张某出资并提供某2公司等多家境内外公司与某3公司等互为上下游公司；陈某某、谢某某受某公司安排负责操作涉案转口贸易事宜；刘某负责提供虚假海运提单。2020年5月，某外汇管理局发现某1公司等在外汇银行办理离岸转手买卖项下付汇业务时提供虚假提单逃汇，遂向公安机关移交线索。案发后，艾某某、陈某某、姜某某、张某、刘某分别退出违法所得人民币348万元。

【案件焦点】

1. 虚假转口贸易中“内保外贷”套利型逃汇行为的认定；2. 犯罪主体身份的认定。

【法院裁判要旨】

广东省广州市天河区人民法院经审理认为：某公司以虚假转口贸易，采取“内保外贷”方式流转资金，利用境内外货币汇率差以及利率差实现融资性套利行为，主观上为利用境内人民币与外汇利率差攫取非法利益，客观上利用虚假转口贸易模式，使外汇从境内流出，再从境外流回，反复套利，使转口贸易空转，挤兑了有限外汇资源，影响宏观经济判断与调控，扩大境内外金融信贷风险，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》等前置性行政法律法规，侵害了外汇管理秩序，具有明显的社会危害性。而艾某某、陈某某、姜某某、张某、刘某、谢某某对于上述虚构转口贸易背景，将外汇非法转移至境

外赚取利差的事实均系知情并积极作为，故某公司以及作为公司其他直接责任人员的艾某某、陈某某、姜某某、张某、刘某、谢某某均具有逃汇的主观故意和实施了逃汇的客观行为，依法均构成逃汇罪。广东省广州市天河区人民法院判决：

综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十条、第五十二条、第五十

三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告单位某公司犯逃汇罪，并处罚金人民币18000万元；

二、被告人艾某某犯逃汇罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；

三、被告人陈某某犯逃汇罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；

四、被告人姜某某犯逃汇罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；

五、被告人张某犯逃汇罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；

六、被告人刘某犯逃汇罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；

七、被告人谢某某犯逃汇罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；

八、被告人艾某某、陈某某、姜某某、张某、刘某退出的违法所得共计人民币348万元予以没收，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案审理过程中，对被告人行为的定性有不同观点。第一种意见认为，不构成逃汇罪。主要理由为：被告单位、被告人虽然通过虚假转口贸易，以内保外贷形式逃汇，并套取利差，但实际上并未造成外汇损失，且转口贸易天然不排斥汇率利差，案发时国家外汇紧缺，银行变相鼓励涉外经营。逃汇罪的立法目的是打击以掏空外汇储备方式扰乱外汇管理秩序的情节严重行为，而本案外汇流转处于闭环状态，被告单位、被告人的行为不具有实质意义上的社会危害性。第二种意见认为，构成逃汇罪。主要理由为：被告单位的行为区别于纯套利型转口贸易行为，通过虚假的转口贸易和内保外贷方式逃汇，不以真实国际贸易为基础，客观上使转口贸易外汇统计失实，影响宏观经济数据，挤占正常转口贸易范围，乃至劣币淘汰良币，有扩

大金融风险之虞，涉案数额近5亿美元，较为严重地破坏了国家外汇管理秩序，应以逃汇罪论处。笔者同意第二种意见。具体理由如下。

一、刑法意义上的逃汇行为：以虚假转口贸易逃汇谋取利差行为的评价

逃汇罪是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将
外汇存放境

外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的行为。首先，从双重违法性角度把握刑法意义上的逃汇行为。逃汇罪的犯罪对象是外汇。从立法沿革看，外汇犯罪经历了一个“犯罪化→非犯罪化→犯罪化”的发展过程，犯罪规制、刑事政策与外汇管理形势紧密关联。逃汇罪是行政犯抑或秩序犯，属《中华人民共和国刑法》第三章第四节破坏金融管理秩序罪章节，行为需达到行政与刑事不法的双重违法性，且社会危害性超越行政违法程度，方纳入刑法评价范畴，罪与罚的界限既存在量的累积，也有质的区别，其刑法调控范围与我国社会经济发展形势息息相关。从《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定的逃汇罪的罪状描述看，该罪具有两种表现形式：一是违反国家规定，将境内的外汇非法转移到境外；二是违反国家规定，擅自将外汇存放到境外。需注意的是，无论是转移境外抑或存放境外，转移或存放的对象既可以是境外银行，也可以是境外单位或个人。从司法实践和国家外汇管理局通报的外汇违规案件来看，逃汇行为一般以前者居多，后者较为少见。《中华人民共和国外汇管理条例》作为前置行政法规，明确了逃汇行为的行政违法性，并为区分罪与罚预留了行政处罚空间。例如，第三十九条规定有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺诈手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。正如，有观点认为：逃汇罪是为了保护外汇储备，行为人将境内的外汇非法转移至境外，随即迅速又转向境内的，不认定犯罪。罪与罚的界限需要考量

外汇安全、主观动机、持续时间以及交易真实性等多层面秩序侵害程度因素，审慎厘定刑法介入调整的合理范围，以衡平打击与保护、规范与引导。

其次，如何评价以虚假转口贸易并采取内保外贷逃汇套利行为？转口贸易 又称中转贸易，是指我国居民将从非居民处购买的货物销售给其他非居民，该 货物直接由生产国运往消费国，~~全程不经过我国境内~~，无海关报关数据作为货物贸易真实性支撑的贸易业务。^①真实转口贸易中的单纯套利行为与逃汇罪有

^①王蕊：《转口贸易风险防范浅析》，载《中国货币市场》2020年第1期。

明显区别，诚然正常转口贸易抑或转口贸易类融资并不排斥附带的套利行为，以真实的国际贸易为基础，金融资金风险较小，对金融秩序造成影响不大。即便如此，将转口贸易套利融资，也不应提倡，毕竟会影响到整体经济运行数据和进一步的外汇调控政策，一定程度上也侵害了外汇管理秩序，尤其是以之为业的，虽不至于纳入逃汇罪规制范围，但可能构成行政违法抑或其他犯罪。

具体到虚假转口贸易而言。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条规定，明确以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为。使用虚假贸易协议或者单证，便属于此种情形。虚假转口贸易中的逃汇行为的可罚性考量，往往不仅是质上，还包括量上的区别。如果说转口贸易真实与否是判断罪与罚的“质”的分界，那么通过转口贸易将外汇非法转移至境外时间长短、有无影响外汇储备以及对外汇管理秩序侵害程度，则为罪与罚的“量”的要素。囿于转口贸易属于中间贸易形式，由传统发展为网络化、融资化的前提下，加之资金流与货物流分离，尤其是难以在境内对应匹配，以致常出现贸易真实性的判断困境。有观点认为：只要外汇没有实质减少，如先外流再等额回流，不宜纳入逃汇罪规制范畴。从实质角度看，无论是假单据型虚假贸易，或者真单据型虚假贸易如一货多用、利用单仓凭持漏洞等，均系虚假转口贸易。非法从事抑或变相从事外汇结算等经营业务，属于非法经营行为，能够从事该结算业务的一般为银行或非银行金融机构，以虚假转口贸易利用外汇套利，与变相从事外汇结算具有一定的同质性特征，具有刑法规制的相当性。虚假转口贸易中套利行为，客观上造成转口贸易统计数据虚增，使本就有限的外汇资源，成为不法分子获取非法利益的工具，增加了金融信贷风险，乃至劣币淘汰良币，不仅影响国家宏观经济判断以及调控，也扰乱外汇管理秩序以及行业规范发展。易言之，以逃汇罪合理规制虚假转口贸易逃汇牟利行为，有行政违法性、刑事违法性以及客观必要性。

本案中，被告单位某公司的主要模式为“内保外贷”型虚假转口贸易，即向境内银行购买理财产品后抵押开具远期信用证，后境内银行向境外银行开具远期信用证，境外银行向境外出货方公司贴现付款，境外出货方公司向境外购

